

1500283-91.2021.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2297015/2021 -

Seccional - Itapeva, 21133753 - Seccional - Itapeva, 3633/21/400 - Seccional -

Itapeva, 2297015 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 3633/21/400 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500283-91.2021.8.26.0622 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500283-91.2021.8.26.0622

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2297015/2021 -

Seccional - Itapeva, 21133753 - Seccional - Itapeva, 3633/21/400 - Seccional -

Itapeva, 2297015 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 3633/21/400 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Garcia Souto

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

LUCIANO GARCIA SOUTO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 20h, na Rodovia SP 281, na altura do quilometro 5, neste município de Itararé, transportava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sete tabletes de maconha, com massa líquida de 5.846,5g, e duas porções grandes de crack, com massa líquida de 497,5g (quatrocentos e noventa e sete gramas e cinco centigramas) substâncias proscritas.

Narra a denúncia que:

"Apurou-se que policiais rodoviários, em patrulhamento de rotina pela rodovia

Francisco Alves Negrão (SP 258), na altura do quilometro 332, avistaram dois veículos parados no acostamento, uma caminhonete Toyota Hilux, prata, placa HJT-7546 e uma caminhonete Ford Ranger, preta, conduzida pelo denunciado Luciano. Nessa ocasião, os agentes públicos visualizaram uma pessoa sair da caminhonete Hilux e deixar um objeto de cor preta na caminhonete Ranger. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos os veículos empreenderam fuga.

Os policiais rodoviários iniciaram o acompanhamento do veículo Ford Ranger pela Rodovia SP 258 e comunicaram as demais guarnições policiais e a guarda civil municipal de Itararé para diligenciarem a encontrar o veículo Hilux.

Após breve acompanhamento, o denunciado Luciano adentrou na Rodovia SP 281, que liga Itararé a Riversul, momento em que dispensou em via pública um involucro grande de cor amarela. Na sequência, na altura do quilometro 5, o denunciado Luciano perdeu o controle do veículo Ford Ranger e tombou no acostamento. Os policiais procederam a abordagem.

Em vistoria, os policiais apreenderam, no interior do veículo Ford Ranger, os tijolos de maconha e duas porções grandes e brutas de Crack, e prenderam o denunciado em flagrante.”

O acusado foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva (fls. 127-134). Determinou-se a notificação do acusado (fls. 300). O acusado apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 315-323).

A denúncia foi recebida em decisão datada de 10 de dezembro de 2021.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e, na sequência, foi interrogado o réu.

Em alegações finais, Ministério Público pleiteou pela procedência da ação (fl. 437-457); e a Defesa postulou o desentranhamento do laudo de fls. 404 a 413, pois foi juntado após o interrogatório do acusado, e no mérito, a absolvição do acusado (fls. 462-473).

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir

Desentranhamento do Laudo Pericial

Não há que se falar em nulidade na juntada do laudo após o interrogatório do acusado.

Em primeiro lugar, o art. 400 do Código de Processo Penal afirma que o interrogatório é o último ato da audiência de instrução e julgamento, o que foi respeitado no presente caso.

Já o art. 402 do Código de Processo Penal, autoriza expressamente às partes e ao juiz, ao final da audiência, “requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. Portanto, o Código de Processo Penal é expresso em autorizar a realização de diligência probatórias, mesmo após o final da audiência, ou seja, mesmo após o interrogatório do réu.

Observo que o precedente do STJ (AgRg no HC 686.418/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (grifos a parte) refere-se antes à hipótese em que foi ouvida testemunha via carta precatória em data posterior ao interrogatório. Trata-se de caso diverso do presente, sendo necessário o distinguishing.

Materialidade

A materialidade foi comprovada, conforme os seguintes elementos probatórios: (i) auto de apreensão das drogas (fls. 31-32); (ii) laudos periciais de constatação (fls. 39-52); (iii) exame químico-toxicológico (fls. 272-275 e 276-279).

Tais documentos descrevem o material apreendido por métodos apropriados e conclui, ao final, tratar-se das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que têm o uso proscrito por figurarem na lista F1 da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (aplicável por força do art. 66 da Lei n.º 11.343, de 2006).

A destinação da droga guardada à traficância restou provada, com absoluta clareza da quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento, manifestamente incompatíveis com a posse para consumo pessoal, conforme os parâmetros do art. 28, §2º, da Lei 11.343, de 2006.

Autoria

A autoria também é certa, uma vez que a prova careada aos autos demonstra, de maneira cabal, que o réu transportava os entorpecentes descritos na denúncia. Primeiro, o réu foi preso em flagrante delito, na posse dos entorpecentes, conforme o auto de prisão em flagrante (fls.01/02) e o boletim de ocorrência (fl. 21-28). Nesse sentido, a testemunha João Paulo Coutinho, ouvido sob compromisso, narrou que estava em patrulhamento e visualizou duas caminhonetes, paradas no acostamento, uma de cor prata e uma segunda preta. Acreditou estar em curso um crime de roubo e optou pela abordagem da caminhonete preta. O condutor da caminhonete preta, contudo, empreendeu fuga e ingressou na rodovia Riversul/SP. A testemunha visualizou o momento em que o condutor dispensou pacotes. Em dado momento, o condutor perdeu o controle do automóvel, o que possibilitou a abordagem. Abordado pelos policiais, o réu apontou que estaria transportando droga de Itararé para Itapeva. Após revista, foram localizados 1 tijolo de maconha e grande quantidade de crack.

A testemunha Matheus, policial militar rodoviário, ouvida sob compromisso, confirmou o depoimento dado por seu colega. Afirmou que visualizou o motorista da caminhonete preta (marca Ranger) jogando fora pacotes. Também confirmou que a parte da droga foi apreendida com o motorista. O motorista da caminhonete preta era o réu. Portanto, não resta dúvida que o réu foi preso transportando os entorpecentes. A testemunha de defesa Lourdes nada alterou no quadro fático, sendo meramente abonatória.

Em seu interrogatório, o réu negou saber que transportava drogas. Disse que fazia bicos transportando mercadoria. Foi contratado, por um desconhecido, para realizar um transporte. Ao chegar no local informado, uma outra caminhonete se aproximou e o condutor entregou um pacote. O indivíduo lhe disse que era para levar para Itapeva. Ao ver as viaturas lhe abordando, imaginou se tratar de um assalto e por isso empreendeu fuga. No trajeto, percebeu que se tratava de droga, e foi a dispensando pelo caminho.

A versão do réu, contudo, não convence, e há diversos elementos que apontam que o réu tinha plena ciência que iria transportar drogas. Em primeiro lugar, logo ao ver a viatura, o réu já empreendeu fuga, o que revela que o réu tinha ciência do material ilícito que transportava. A alegação de que imaginava se tratar de um "assalto" não prospera, uma vez que o réu, ao invés de rumar em direção à Itapeva, empreendeu fuga pela estrada de Riversul, ou seja, tentando despistar os policiais e não buscar ajuda na cidade. Em segundo lugar, a grande quantidade de maconha possui cheiro e maneira de acondicionamento característicos, que seriam de pronto percebidos pelo transportador. Em terceiro lugar, o réu começou a dispensar os tijolos de maconha na estrada, e não soube explicar porque começou a fazer isso se imaginava estar sendo assaltado.

Em suma, a versão do réu se mostrou dissociada do arcabouço probatório, sendo inviável se falar em erro de tipo, como alega a defesa.

Causa de Diminuição (art. 33, §4, da Lei 11.343/06)

Deve-se reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por satisfeitos os requisitos legais.

Primeiro, o réu é primário e de bons antecedentes (fl .115-116)

Segundo, não há elementos concreto que demonstrem que eles se dedique a atividades criminosas, não havendo qualquer inquérito ou ação penal em curso em face do réus(vide STJ. 3a Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596). Pelo contrário, o acusado possui 46 anos, e jamais foi condenado criminalmente ou investigado.

Terceiro, não há indícios que o réu integre organização criminosa. Nesse sentido, percebe-se que a quantidade de droga apreendida não permite concluir, por si, a participação do réu em organização criminosa. Nesse sentido vale mencionar que "a quantidade de drogas não constitui isoladamente fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena" (STF, HC 138.138/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 29.11.2016, noticiado no Informativo 849).

Ademais, a prisão não decorreu de investigação prévia, mas sim de ação policial isolada, e não foram produzidos elementos de prova para demonstrar, de forma cabal, a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua participação no crime organizado.

Em especial, a qualidade de "mula", ou seja daquele que transporta drogas em favor de organização criminosa, não impede o reconhecimento do redutor, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ.

Por fim o laudo de fls. 404-413 não trouxe nenhum elemento concreto acerca do envolvimento do réu com atividade criminosa/organização criminosa.

Logo, satisfeitos os requisitos, faz jus o réu ao redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Individualização da Pena

De rigor, assim, a condenação pelo crime de tráfico de drogas o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas, conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ao crime do art. 33, caput, da Lei 11/343/06, são cominadas, em abstrato, as penas de reclusão, de cinco a 15 anos, e multa.

Para a dosimetria, parte-se, portanto, da pena mínima de 5 ano de reclusão e 500 dias multa (art. 49 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, no tocante às circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06 observo que a natureza da droga apreendida, em especial, por se tratar de "crack", justifica a exasperação diante da qualidade especialmente nociva desse tipo de entorpecente.

Também a quantidade de droga excede à normalidade das apreensões nesta comarca. As circunstâncias do art. 59 do Código Penal não chegam a ser desfavoráveis ao acusado.

Ressalto que utilizo, por coerência às penas cominadas pelo legislador e em obediência ao princípio da proporcionalidade, o critério matemático de elevar a pena-base em um nono (pois nove são as circunstâncias judiciais aplicáveis aos crimes da Lei n. 11343/06) do resultado da subtração da pena máxima pela pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 7 ano(s), 2 mês(es) e 20 dia(s) de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes ou agravantes. Portanto, a pena-provisória é fixada, tal qual a pena-base, em 7 ano(s), 2 mês(es) e 20 dia(s) de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, deve-se aplicar a minorante do art. 33, §4, da Lei 11.343/06 no quantum máximo de diminuição de 2/3, uma vez que não há elementos nos autos aptos a justificar uma redução para aquém desse patamar.

Observo que a quantidade e natureza da droga devem ser valoradas, necessariamente de acordo com a jurisprudência do C. STJ, na 1ª fase da dosimetria nos termos do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), conforme feito supra.

Nesse sentido:

[...]NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER NECESSARIAMENTE OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.

****IMPOSSIBILIDADE****. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. [...]

[...] No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, ****uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.****

Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

Apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base.

(STJ. HC 665.401/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/6/2021).

13 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 580.641/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)"

Com tais considerações, fixo a pena definitiva ao acusado em 2 ano(s), 4 mês(es) e 27 dia(s) de reclusão.

Adotando o critério da proporcionalidade entre os limites mínimo e máximo da pena de multa e os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito em tela, fixo a pena de multa em 240 dias-multa, sendo cada dia-multa o equivalente a 1/30 do salário-mínimo, o mínimo legal, até porque não comprovada capacidade econômica do(a) acusado(a) que autorize o apontamento de valor mais elevado.

Com fundamento no art. 33, § 2º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o regime aberto.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a substituição da pena privativa de liberdade. Em face do montante da pena aplicado, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a seguir especificadas: (i) prestação de serviço a entidade beneficente local, a ser definida oportunamente; e (ii) prestação pecuniária, no valor de hum salário mínimo .

A substituição da pena privativa de liberdade é mais benéfica e, por isso, prejudica a aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que o delito praticado não tem vítima específica.

Da detida análise dos autos e à luz do art. 316 do Código de Processo Penal, extrai-se que deve ser modificada a situação processual do(a) acusado(a). Isso porque, fixado o regime aberto, este se mostra incompatível com a manutenção da prisão preventiva, a qual deve, então ser revogada.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO LUCIANO GARCIA SOUTO pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e § 4º, da Lei 11343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 2 ano(s), 4 mês(es) e 27 dia(s) de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de pena de multa no valor de 240 dias-multa, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 do salário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a seguir especificadas: (i) prestação de serviço a entidade beneficente local, a ser definida oportunamente; e (ii) prestação pecuniária, no valor de hum salário mínimo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Determino a incineração da droga apreendida.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado, respeitada a gratuidade.

*

Itararé, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA